Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
18ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent18vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5118158-32.2021.8.21.0001/RS

AUTOR: ELENIR DOS SANTOS FRICK

RÉU: UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

ELENIR DOS SANTOS FRICK ajuizou **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** em desfavor de **UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA.,** narrando ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré desde 01/9/1998. Alegou ter sido diagnosticada com neoplasia mamária maligna metastática para ossos com receptores hormonais positivos (CID-C 50.9, EC IV), tendo sido prescrito os medicamentos Ribociclibe - KISQALI EYUE, 200 mg, e LETROZOL, 2,5 mg. referiu que, posteriormente, a comercialização de seu contrato foi suspensa pela ANS, sem que lhe fosse ofertada a possibilidade de migração para plano adaptado a Lei nº 9.656/98. Referiu que diante do diagnóstico e tratamento prescrito por seu médico, encaminhou pedido para que a demandada fornecesse as medicações, o que foi negado. Posteriormente, gizou ter solicitado a reanálise do pedido, a qual foi reconsiderada parcialmente, ao efeito de ser autorizado o tratamento quimioterápico para uso intravenoso, mantido o indeferimento com relação aos medicamentos para uso via oral e contínuo. Defendeu a necessidade da realização de tratamento global nos moldes em que prescritos pelo médico. Invocou dispositivos legais e jurisprudência em favor de sua tese, referindo a obrigação da requerida em custear os medicamentos. Pediu AJG. Formulou pedido liminar para que a ré forneça os medicamentos. Requereu a procedência da ação com a confirmação da tutela de urgência. Juntou procuração e documentos (Evento 1).

Deferido o pedido liminar (Evento 3). Desta decisão, a parte ré interpôs recurso de agravo, o qual restou desprovido (Evento 9).

Sobreveio manifestação da ré noticiando o cumprimento da liminar (Evento 14).

Citada, a parte ré apresentou contestação. No mérito, sustentou a inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98, uma vez que o contrato foi firmado entre as partes em data anterior à vigência da lei dos Planos de Saúde. Invocou a ADPF nº 1.931, de modo que a relação havida entre as partes é regida exclusivamente pelas cláusulas contratadas. Afirmou a existência de exclusão de cobertura para fornecimento de medicamentos, o que não afronta o CDC. Insurgiu-se contra a utilização da medicina baseada em evidência (MBE), destacando a necessidade de consulta aos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciária - NATJUS. Requereu a improcedência da ação. Acostou procuração e documentos (Eventos 7 e 15).

Sobreveio manifestação da parte autora (Evento 20).

Deferida a AJG à demandante, bem como instadas as partes sobre a necessidade de produção de provas (Evento 22), a parte ré requereu consulta ao NATJUS (Evento 27); tendo a parte autora apresentado réplica e requerido prazo para a juntada de laudo médico atualizado, além de perícia médica (Evento 28).

Indeferido o pedido de consulta deduzido pela ré (Evento 31).

Sobreveio manifestação da ré postulando o julgamento antecipado da lide (Evento 35).

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Cabível o julgamento antecipado da lide, tendo em vista a desnecessidade de produção de outras provas, estando os fatos suficientemente esclarecidos, motivo pelo qual, desnecessária se revela a realização de perícia, de modo que aplicável a regra prevista no art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Na ausência de preliminares ou nulidades passo à análise do mérito.

Busca a parte demandante que a ré forneça à parte autora, por tempo indeterminado, os medicamentos Ribociclibe - KISQALI EYUE, 200 mg e LETROZOL; 2,5 mg (vide Evento 1; ATESTMED7) , conforme expressa indicação médica.

1. <u>Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor</u>

Observo que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Aliás, este é o entendimento da Súmula nº 608 do STJ, que substituiu a Súmula nº 469, nos seguintes termos.

Súmula nº 608: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."

Há entendimento proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.931, por meio do qual estabeleceu-se que os contratos celebrados antes da vigência da Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) não podem ser atingidos pela sua regulamentação. Assim, à luz desse paradigma e tendo em vista que o contrato em questão foi firmado antes da vigência da LPS, mostra-se inaplicáveis as disposições da referida lei.

Incidem, todavia, ao presente caso, as disposições previstas no contrato firmado entre as partes e as normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante Súmula nº 608 do STJ.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO NÃO REGULAMENTADO. EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL QUE AFASTA A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA POR PARTE DA OPERADORA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LICITUDE DA CONDUTA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. 1. Tratando-se de contrato não regulamentado, firmado anteriormente à vigência da Lei nº 9.656/98, aplicam-se tão somente as disposições nele previstas e as normas do Código de Defesa do Consumidor, quando não administrado por entidade de autogestão. Inteligência do verbete nº 608 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Dada a especificidade do contrato não regulamentado pela Lei nº 9.656/98, bem assim diante a ausência de adaptação às novas regras dos planos de saúde, não há obrigatoriedade da operadora em fornecer cobertura, diante de expressa exclusão contratual. 3. Ausente a obrigatoriedade da operadora em fornecer a cobertura contratual, resta afastada a ilicitude da negativa e, por consequência, dos danos morais, uma vez ausente um dos pressupostos da indenizabilidade, na forma do disposto nos arts. 186 e 927 do Código Civil DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.(Apelação Cível, Nº 70083261081, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 05-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. EXAME PET CT ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA. COBERTURA DEVIDA. DANO MORAL. Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenizatória, através da qual a parte autora postula o fornecimento do exame denominado PET CT, bem como indenização por danos morais, julgada parcialmente procedente na origem. Os contratos de seguro e de planos de assistência à saúde devem se submeter às disposições do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que tratam sobre relações de consumo, nos termos do artigo 3º, §2º, da legislação consumerista, bem como em face do disposto na Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Incontroverso nos autos, que a parte autora era portadora de Neoplasia de Colon metástica para fígado, tendo o médico que lhe atendia prescrito o exame PET CT, com urgência, nos termos do laudo médico de fl. 08 dos autos. A parte autora era usuária do plano de saúde na modalidade PIAS 21S - Familiar, desde 1995 – Contrato não regulamentado -, ou seja, anteriormente ao advento da Lei nº 9.656/98, o que representaria a inaplicabilidade da referida lei ao caso concreto. Saliento que não desconheço que o Plenário do STF julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1931, que questiona a Lei nº 9.656/1998 onde, por unanimidade dos votos, a Corte entendeu que os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde ao declarar a inconstitucionalidade do art. 10, § 2º e art. 35-E, ambos da Lei nº 9.656/98, portanto, não haveria obrigatoriedade por parte da operadora do plano de saúde de oferecer o plano referência (regulamentado) aos clientes beneficiários de planos não regulamentados, o que afasta por completo a aplicabilidade da Lei 9.656/98 e, consequentemente, a extensão da cobertura prevista para o plano de referência aos contratos firmados antes da referida Lei e a ela não adaptados. Porém, em recentes julgados exarados pelo egrégio STJ, restou consolidado que as regras estabelecidas na Lei nº 9.656/98 restringem-se aos contratos de plano de saúde celebrados após a sua vigência (art. 35), mas o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor. No caso dos autos, a cláusula 6ª do contrato entabulado entre as partes prevê cobertura para exames complementares (fl.57), bem como a cláusula 12 que estabelece os limites de cobertura contratual não elenca o exame postulado, de modo que não há expressa exclusão de cobertura (fls.59/60). Assim, se há cobertura para o tratamento receitado à parte autora, não é razoável que a demandada se recuse a custear exame fundamental para o diagnóstico e definição do tratamento da doença. DUPLA APELAÇÃO. APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMERNETE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDA(Apelação Cível, Nº 70083629063, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 30-04-2020)

Assim, a hipótese dos autos é de relação de consumo, porquanto se vislumbra, na presente lide, negócio envolvendo prestação de serviços e consumidor final, a teor do disposto no artigo 2º da Lei nº 8.078/90, não se tratando, ainda, de plano de saúde administrado por entidades de autogestão. Sendo assim, aplicáveis as disposições da Lei Consumerista à espécie.

2. <u>Da cobertura dos medicamentos requeridos pelo autora</u>

A parte autora sofre de neoplasia mamária maligna metastática para ossos com receptores hormonais positivos (CID-C 50.9, EC IV), cujo tratamento recomenda a utilização dos seguintes medicamentos: Ribociclibe - KISQALI EYUE, 200 mg a ser utilizado por 21 dias, a cada 28 dias, em média oito caixas com 63 comprimidos por ano; e LETROZOL; 2,5 mg para uso contínuo de um comprimido por dia (vide Evento 1; ATESTMED7)

Após pedido formal para que o plano de saúde custeasse o referido fármaco, o demandado apresentou negativa de fornecimento alegando que não há cobertura contratual, na medida em que há cláusula expressa no contrato de exclusão da cobertura de medicamentos que não exigem internação hospitalar, como no caso. Além disso, referiu que a Lei dos Plano de Saúde (Lei nº 9.656/98) não se aplica à situação, já que o contratação do plano foi realizada antes do início da vigência da lei.

Quanto à alegação da inaplicabilidade da Lei nº 9.656/98 ao caso, de fato, assiste razão à parte ré, uma vez que tendo sido firmado o contrato de plano de saúde antes da vigência da referida legislação, incidem ao presente caso somente as normas consumeristas e as disposições estabelecidas no contrato avençado entre as partes.

Todavia, com relação às cláusulas contratuais que supostamente afastariam a cobertura do fornecimento dos medicamentos, não prospera a tese defensiva.

O contrato celebrado entre as partes prevê na cláusula IX os serviços com e especialidades médicas com cobertura de tratamento do plano de saúde contratado. A referida cláusula estabelece que a Unimed somente fornecerá medicamentos prescritos pelo médico que advierem de internação hospitalar, *in verbis* a cláusula (Evento 15 – CONTR3, página 03):

CLÁUSULA IX - SERVIÇOS ASSEGURADOS (ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, AMBULATORIAL E PROCEDIMENTOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA)

9.1. - A CONTRATADA assegura aos usuários inscritos, **após o cumprimento dos períodos de carência,** assistência médica nos consultórios dos médicos cooperados, em hospitais e ambulatórios, **dentro da rede própria ou contratada, de acordo com o (s) módulo (s) contratado (s),** nas especialidades clínicas e/ou cirúrgicas a seguir relacionadas: alergologia e imunologia; anestesiologia; angiologia; cardiologia (**excluídas as cirurgias**), citopatologia; clínica médica ou medicina interna; dermatologia; endocrinologia e metabologia; fisiatria; gastroenterologia; geriatria; genética clínica; ginecologia; hematologia; homeopatia (**somente consultas**); infectologia; nefrologia; neurologia; neurocirurgia clínica; oftalmologia; oncologia (cancerologia); ortopedia; otorrinolaringologia; pediatria; pneumologia; proctologia; psiquiatria (**somente consultas**); reumatologia; traumatologia; urologia.

9.1.1. - **A Cirurgia Plástica Reparadora terá cobertura contratual quando efetuada, exclusivamente, para restauração de funções em órgãos, membros e regiões lesadas em virtude de acidentes pessoais ou tratamento cirúrgico ocorridos na vigência do presente contrato e que estejam causando problemas funcionais.**

9.2. - A CONTRATADA assegura aos usuários, **durante a internação**, os seguintes serviços hospitalares: a) assistência médica através de médicos cooperados; b) medicamentos prescritos pelo médico assistente; c) alimentação dietética ou normal (**excluída a parenteral e enteral**); d) serviço de enfermagem, **exceto em caráter particular;** e) diárias de internação hospitalar **em quarto coletivo**, taxas de internação e de sala; f) material de sala, de acordo com o porte cirúrgico; g) exames complementares especializados para diagnóstico, controle de tratamento e evolução da doença que tenha motivado a internação, **exceto os não cobertos por este contrato;** h) anestésicos, oxigênio e hemoterapia.

9.3. - A CONTRATADA assegura aos usuários, nos termos deste contrato, os serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, **exclusivamente dentro dos recursos contrados para este módulo, quando solicitados por médicos cooperados, conforme descrito na Cláusula VI.**

Outrossim, a negativa da parte ré para custear o medicamento pleiteado pelo autor foi no seguinte sentido:

O contrato supramencionado foi firmado anteriormente à Lei nº 9.656/98 e, não se aplicando ao que dispõe este manto normativo e, consequentemente, excluído da regulação estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, no que tange à cobertura mínima obrigatória. Sendo assim, a cobertura e regramento restringem-se às cláusulas contratuais previstas no instrumento tabulado entre as partes no ato da adesão, bem como aos direitos contratuais preconizados no ordenamento jurídico brasileiro.

No caso em questão, houvera a solicitação, em caráter eletivo, dos eventos médicos "*Terapia oncológica - planejamento e 1 dia de tratamento, código 20104294; KISQALI 200 MG/DOSE COM REV CT BL, código 90409795; FEMARA 2,5 MG COM REV CT BL AL, código 90170555*", pelo Dr. Ricardo Moacir Silva, inscrito no CRM sob o nº 24.335.

No tocante aos eventos, considerando o exposto acima acerca das disposições aplicáveis à contratos não regulamentados, salienta-se que estes não possuem cobertura contratual prevista, havendo, neste sentido, cláusula de exclusão expressa, nos seguintes termos:

> *CLÁUSULA X - SERVIÇOS EXCLUÍDOS*
> *10.1. - ESTÃO EXCLUÍDAS DAS COBERTURAS DESTE CONTRATO AS DESPESAS REFERENTES A:*
> *[...]*
> *O) medicamentos e materiais cirúrgicos, exceto em interações e atendimento em pronto-socorro; [...] (grifo nosso)*

Isto posto, a negativa vem fundamentada na solicitação, para a realização dos eventos médicos, fora das limitações previstas no rol de coberturas traçados no contrato celebrado entre as partes, abrangendo evento com exclusão expressa. É consolidado o entendimento nos tribunais,

Apesar de a demandada ter indicado a cláusula X - Item 10.1. letra "O" do contrato para embasar a negativa de cobertura - alegando que, por não ser medicamento relacionado à internação hospitalar e a atendimento em pronto-socorro estaria fora da cobertura prestada pelo plano de saúde -, também apontou que as medicações não possuem aplicação intravenosa, o que reforçaria a exceção prevista no contrato.

Porém, o que se observa é uma enorme disparidade e antagonismo entre as próprias cláusulas do contrato do plano de saúde e os motivos pelos quais a negativa de cobertura foi amparada, ao excluir o fornecimento de medicamento de que necessita o paciente a partir do fato de estar ou não internado no hospital ou se o atendimento se deu no pronto-atendimento.

Assim, incide, na espécie, o disposto no art. 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, de maneira que deve ser fornecido à autora os medicamentos de que necessita, desimportando o fato de a autora não estar internada.

Registre-se que as exclusões e limitações impostas pelos planos de saúde devem ser avaliadas com ressalvas, já que se trata de típica relação de consumo, a ser adequada ao Diploma Consumerista.

Veja-se a previsão do disposto no art. 51, IV, § 1º, II, do CDC, *in verbis*:

> *Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:*
>
> *(...)*
>
> *IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;*
>
> *§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:*
>
> *(...)*
>
> *II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;*

Os princípios de ordem pública do Diploma Consumerista integram o contrato para recompor a vulnerabilidade existente entre a administradora do plano de saúde e o consumidor. Note-se que tal interpretação está, ainda, em consonância com o art. 423 do Código Civil que assim dispõe:

> *Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)*

Cabe ao profissional da saúde, responsável pela assistência da parte autora, a prescrição do tratamento mais adequado e eficaz do ponto de vista médico terapêutico para o caso específico. Assim, desimporta o fato de a autora não estar internada em hospital para fazer jus à medicação de que necessita. Se o contrato prevê cobertura para a patologia que

acomete o paciente, o plano de saúde deve ser compelido a fornecer o medicamento prescrito, principalmente se o fármaco for apontado como essencial para o tratamento da doença que acomete o segurado, como no caso em questão.

Acresço, pela pertinência, a seguinte consideração feita pela Instância Superior, ao exame do Agravo de Instrumento nº 5207209-09.2021.8.21.7000, em que mantido o deferimento da medida liminar: *"E, esse, com efeito, é o caso dos autos, pois além de se tratarem de medicamentos indicados pelo médico assistente para o tratamento de câncer de mama, após tentativa de diversos outros tratamentos sem resposta, o fármaco Ribociclibe, em razão de sua eficácia cientificamente comprovada, com a edição da Resolução Normativa nº 465/2021, passou a constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde como indicação para o tratamento de câncer de mama. E, o medicamento LETROZOL, por sua vez, sempre esteve presente na listagem da ANS, de forma que abusiva a negativa exarada pelo plano de saúde"* (Evento 9).

Evidentemente, compete apenas ao médico que tem contato direto com o paciente decidir a terapêutica mais adequada a ser utilizada, pois é aquele o profissional habilitado para apurar as verdadeiras condições de saúde do doente.

No caso, o atestado médico foi claro ao indicar a indispensabilidade dos medicamentos ao tratamento da moléstia da autora (Evento 1; ATESTMED7):

> Atesto que a senhora **ELENIR DOS SANTOS FRICK**, é portadora de neoplasia de mama com receptores hormonais positivos, metastática para ossos, CID C 50.9, EC IV e que necessita do uso da medicação ribociclibe (dose de 600 mg/dia por 21 dias, a cada 28 dias) em combinação com letrozol (dose de 2.5 mg, por via oral, 1x/dia, uso contínuo). A combinação da medicação ribociclibe ao letrozol oferece, nos dias atuais, maior taxa de resposta tumoral, maior taxa de sobrevida livre de progressão tumoral e maior taxa de sobrevida global, constituindo-se na melhor alternativa terapêutica disponível.
>
> Atesto que a paciente necessita iniciar o uso de ribociclibe dentro das próximas 2 semanas sob risco de progressão da doença com consequente piora clínica e morte. Além disso, atesto que nem seu convênio de saúde e nem o SUS (Sistema Único de Saúde) disponibilizam medicação que possa substituir o ribociclibe e que o plano inicial do tratamento é manter por tempo indeterminado.

Dessa forma, com base na legislação consumerista aplicável ao caso, deve a demandada Unimed fornecer a cobertura das medicações de que necessita a parte demandante, para a salvaguarda de sua saúde e qualidade de vida.

Nesse passo, a procedência da ação é medida que se impõe.

III - <u>DISPOSITIVO</u>

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTE** a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por ELENIR DOS SANTOS FRICK contra UNIMED NOROESTE/RS - SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para o fim de **CONDENAR** a parte ré a fornecer à parte autora, por tempo indeterminado, os medicamentos Ribociclibe - KISQALI EYUE, 200 mg a ser utilizado por 21 dias, a cada 28 dias, em média oito caixas com 63 comprimidos por ano; e LETROZOL; 2,5 mg para uso contínuo de um comprimido por dia (vide Evento 1; ATESTMED7), CONFIRMANDO a tutela de urgência deferida no Evento 3.

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da parte *ex adversa*, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, considerando o trabalho desenvolvido e a natureza da demanda, de acordo com art. 85, § 2º, do CPC.

Por derradeiro, tendo em vista a nova sistemática do Código de Processo Civil e diante da inexistência de juízo de admissibilidade, conforme dispõe o artigo 1.010, § 3º, do CPC, em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se na intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, remetam-se os autos ao egrégio TJRS.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 5 (cinco) dias e satisfeitas eventuais custas pendentes, arquive-se com baixa.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA ELIZABETH MICHEL SCALABRIN DI LORENZO, Juíza de Direito**, em 4/11/2022, às 17:47:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10023756714v26** e o código CRC **ef944091**.